

0013273-10.2014.8.26.0405

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2084/2014 - 10º Distrito Policial de Osasco

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cleiton Gonçalves de Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual CLEITON GONÇALVES DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco-SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0013273-10.2014.8.26.0405 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0013273-10.2014.8.26.0405

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2084/2014 - 10º Distrito Policial de Osasco

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cleiton Gonçalves de Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual CLEITON GONÇALVES DE LIMA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.346/06 (fls. 77/79).

Narra a denúncia que no dia 27 de abril de 2014, por volta das 11h30min, na Rua Reverí, n. 38, Helena Maria, nesta cidade e Comarca de Osasco, o acusado, guardava e tinha em depósito, drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para consumo de terceiros, consistentes em 53 invólucros plásticos, do tipo "eppendorf", de cocaína, no total de 28g e 31g invólucros plásticos de cocaína na forma de "crack", no total de 5,6g, conforme laudo de constatação (fls. 1-D/2-D).

Narra a inicial que policiais militares dirigiram-se à residência do denunciado para averiguarem uma suspeita de participação deste em um crime de roubo. No local, tiveram a entrada ao terreno franqueada pela testemunha Consuelo, moradora do mesmo lote. O imóvel, por sua vez, estava com a porta aberta, de forma que os policiais tiveram acesso a seu interior. Em busca domiciliar, os policiais lograram localizar, dentro da geladeira, dentro de um estojo, as porções de cocaína e, no interior de um armário, as pedras de "crack", além de setenta e três "eppendorfs" vazios.

Notificado a apresentar defesa prévia o acusado assim fez às fls. 49/51, por intermédio da Defensoria Pública.

A denúncia foi recebida às fls. 55.

O réu se encontra em gozo de liberdade provisória.

Laudo de exame químico toxicológico (fls. 60/61).

O réu foi inicialmente interrogado (fls. 85).

Foi ouvida uma testemunha de acusação (fls. 86).

Foi designada nova audiência de instrução. Em audiência concentrada foi ouvida outra testemunha e acusação e o réu novamente interrogado.

O Ministério Público, em debates, pediu a condenação nos termos da inicial.

A Defesa requereu, também em debates, pediu a absolvição por falta de provas, especialmente diante de sua ilegalidade. Subsidiariamente, a pena fixada no mínimo legal, o redutor máximo e conversão em pena restritiva de direito.

É o relatório

Fundamento e decido.

O pedido é improcedente.

Com efeito, a finalidade epistêmica do processo penal é a busca da verdade, ainda que de forma aproximada, por meio de reconstrução fática que leve a superação do postulado da presunção de inocência. Entretanto, este objetivo teleológico deve ser buscado com respeito as regras legais e constitucionais de produção e valoração das provas. Não é possível, dentro de um processo penal de índole democrática, a valoração da prova ser dissociada da ideia de legalidade. A legalidade da prova é um pressuposto do juízo de mérito. O processo não é um fim em si mesmo e a verdade não pode ser buscada a qualquer custo, ainda mais havendo sacrifício de direito individual. Antes de qualquer valoração racional é sempre necessário o escrutínio da fonte da prova.

Nesse sentido: “assim, no Brasil, os códigos processuais, civil e penal, dispõem justamente acerca da validade da prova da verdade, que deverá seguir um trâmite que não cause surpresa às partes (livre acesso), que amplie sua participação no discurso relacionado ao seu enunciado (contraditório), que seja adequada e idônea ao fato que se quer provar e que não seja obtida por meios ilícitos. A busca da verdade não é, assim, orientada para a obtenção da verdade substancial, mas apenas da verdade provavelmente admitida. Não vigora mais, assim, no processo a busca da verdade real. Até porque, como já se disse, não existe essa suposta verdade real. Seria uma pretensão audaciosa do direito entender que o juízo possa fazê-lo unicamente pelos instrumentos legais.” (TAVARES, Juarez, CASARA, Rubens. Prova e verdade. 1ª ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020, p. 147).

O Código de Processo Penal, saliente-se, adotou o sistema do livre convencimento objetivo motivado do juiz, pelo qual incumbe ao magistrado formar sua convicção a partir da livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, desde que fundamentadamente. Em outras palavras, não é lícito ao julgador formar sua convicção e, por conseguinte, proferir sentença condenatória com base em elementos colhidos ao arrepio de direitos individuais. O material probatório levado à análise judicial deve se revestir de legalidade, o que não se verifica no presente caso.

A sentença, portanto, é fundamentada em dois argumentos e ambos convergem para a absolvição: a) o primeiro é que toda prova é ilícita pois deriva de violação de direito constitucional – ingresso em domicílio sem justa causa prévia, fora, portanto, das hipóteses constitucionais; b) o segundo é que, mesmo que superado o argumento anterior, a versão dos policiais é totalmente dissonante e sem elemento externo de corroboração, até porque, diante do conteúdo lacônico da versão do policial Eduardo (fls. 86 – colhido por outro Magistrado) sequer é possível sua comparação com a versão do policial Rogério colhido hoje em audiência.

A dinâmica fática relatada pelos policiais, em resumo, consiste no fato de que estavam em patrulhamento e avistaram um veículo que era suspeito de ser produto de roubo praticado a residência um ou dois dias antes. O veículo era ocupado por três pessoas. O réu era o condutor. Nada de ilícito fora encontrado no veículo. Por esta razão o réu foi levado à Delegacia de Polícia. Já na Delegacia de Polícia o réu informou aos policiais militares o endereço em que residia. Uma equipe de policiais militares se dirigiu à residência do réu sob a alegação de buscar objetos subtraídos anteriormente da aludida residência. Os policiais, segundo inclusive a versão da testemunha Rogério, sem que o réu acompanhasse a diligência, obtiveram a autorização para ingresso na residência da proprietária do imóvel – na verdade locatária (informação esta que souberam na delegacia de polícia). Em busca domiciliar, segundo os policiais, nenhum objeto do roubo foi localizado, contudo, na geladeira encontraram a droga descrita na inicial.

Pois bem. De início, cumpre salientar que a ilegalidade do ingresso domiciliar, antes de mais nada, está descrita na própria inicial do Ministério Público. Segundo a acusação, os policiais tiveram a entrada franqueada pela testemunha Consuelo, moradora não da casa, mas do mesmo lote que o réu. Ao ingressarem no terreno comum os policiais viram que o imóvel estava com a porta aberta. Aproveitando-se desta situação – porta aberta – ingressaram no imóvel e realizaram a busca.

Por outro lado, pelas razões abaixo descritas, com base especialmente no relato da testemunha Rogério, a ilegalidade, para além do que constante na inicial, é manifesta.

Com efeito, anote-se que, mesmo sendo o crime do art. 33 da Lei de Drogas de natureza permanente, especialmente os núcleo típico guardar (este imputado na denúncia), fixou o Superior Tribunal de Justiça, por meio de atividade interpretativo-teleológica no sentido de trazer conteúdo concreto ao pressuposto legal “fundadas razões” (expressão jurídica indeterminada), no voto condutor do

Ministro Rogério Schietti, alguns standard probatórios para validade da prova, dentre eles haver fundadas razões que justifiquem a entrada em domicílio alheio fora as hipóteses constitucionais, que devem ir além da “mera atitude suspeita” ou “fuga do indivíduo em direção a sua casa”. (Habeas Corpus n. 598.051 – SP. Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – 6ª Turma, j. 02.03.2021). Anote-se, por oportuno, que este leading case orientou a unificação do entendimento das duas turmas do Superior Tribunal de Justiça no (Habeas Corpus n. 616.584 – RS – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – 5ª Turma, j. 30.03.2021).

Assim: (...) 2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legítima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação – e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio – justificam o retardo da cessação da prática delitiva. (...) 4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude “suspeita”, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente. (...) 6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência – uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio – outros países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso alheio. (...) 7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação – como ocorreu no caso ora em julgamento – de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade. 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral – pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro – e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado. (...)

Saliente-se, por oportuno, que a questão aqui apreciada já foi objeto de amplo debate na jurisprudência também do STF. O Pleno da Suprema Corte, por maioria de votos, no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616-RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 05/11/2015, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.

Postas estas premissas jurisprudenciais-doutrinárias, no caso dos autos percebe-se que a localização de drogas, além de derivar de ingresso ilegal na residência,

também derivou de sorte.

Os policiais militares, em atividade de investigação típica da polícia judiciária, foram à casa do réu com vistas a encontrarem objetos subtraídos quando do roubo à residência ocorrido 1 ou 2 dias após os fatos. Sem a presença do réu e de autorização de quem de direito (Consuelo era locatária do imóvel) ingressaram no local e, segundo alegam, acharam drogas. Não há, portanto, relação entre este argumento (diligências para localização de produtos de roubo) e o ingresso na residência e posterior apreensão de drogas. Há, portanto, claro desvio de finalidade na conduta dos policiais até porque não havia qualquer informação acerca de drogas. O encontro das drogas na geladeira se deu de modo fortuito eis que não estava no espectro de alcance da atividade policial a apreensão de drogas. Tratou-se, de fato, de verdadeira investigação especulatória ou fishing expedition.

Em segundo lugar, ainda que sustente a testemunha que Consuelo tivesse se apresentado como proprietária do imóvel e somente na delegacia informado que era locatária, este argumento não valida a diligência de polícia judiciária levada a efeito pelos policiais militares. Pode ser alegada para eventual escusa por parte dos policiais em qualquer tipo de apuração, mas não para tornar lícito algo originariamente ilícito até porque, por óbvio, Consuelo não possuía a prerrogativa de autorizar a entrada na casa de terceiros. Não houve, portanto, anuência expressa ou tácita, livre e consciente, do acusado ou de quem de direito (morador da casa) para o ingresso domiciliar.

Assim, por todos os lados em que se analisa a questão, não havia fundadas razões para o ingresso domiciliar sem autorização judicial ou de quem de direito.

Por outro lado, ainda que se supere o escrutínio de legalidade, as provas não demonstram, com a segurança, para além da dúvida razoável, a premissa fático-acusatória de que o acusado guardava e tinha em depósito, drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para consumo de terceiros, consistentes em 53 invólucros plásticos, do tipo "eppendorf", de cocaína, no total de 28g e 31g invólucros plásticos de cocaína na forma de "crack", no total de 5,6g, conforme laudo de constatação.

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória não é suficiente a justificar a reponsabilidade penal do réu.

Ainda que demonstrada a existência material do crime (laudo de exame químico toxicológico - fls. 60/61), quanto a autoria as provas valoradas em contraditório judicial não permitem com a segura e devida convicção o decreto condenatório do réu em relação ao delito de tráfico (art. 33 "caput"). Em outras palavras, as incongruências apresentadas pelos policiais, unidas à falta de outros elementos que comprovem a diligência, para além da versão extraída da memória, não apresentam uma garantia epistêmica suficiente que justifique a imposição de pena.

O réu, em juízo, negou os fatos. Não reconheceu a propriedade das drogas.

A testemunha Eduardo mostrou-se lacônica e nada explicou sobre o contexto de apreensão das drogas e sequer o local onde foram apreendidas e quais seriam as drogas.

A testemunha Rogério tentou justificar principalmente o ingresso na residência contudo sobre as drogas não trouxe informações precisa, especialmente devido ao tempo do processo.

Anote-se que nesta fase de valoração da prova a qualidade de policial, por si só, não infirma a prova ou a torna mais importante. Não é porque a pessoa é policial e que participou da ocorrência que sua versão ganha mais ou menos credibilidade. A credibilidade da versão apresentada deve ser valorada de forma racional de maneira

a verificar se ela possui coerência interna e, ainda, se possui coerência externa quando corroborada com as demais provas apresentadas. No caso dos autos, as testemunhas policiais apresentam versões claudicantes e pouco plausíveis, e, acima de tudo, não podem ser corroboradas por outros elementos de prova. Assim, coligindo os relatos dos policiais não há provas seguras de o réu guardava drogas. Aliás, não foi possível o escrutínio da prova produzida em juízo.

Portanto, a versão do réu não restou suficientemente afastada. As provas não foram capazes de superar o postulado da presunção de inocência.

A única certeza dos autos é o encontro da droga. Entretanto, a autoria por parte do acusado das condutas típicas afirmadas pela acusação na inicial, com base nas provas colhidas em contraditório judicial, permanece obnubilada.

O direito penal, frise-se, não se contenta com conjecturas, nem mesmo com probabilidade de autoria. A moderna dogmática penal e processual penal exige a convicção plena do julgador, base ética indeclinável amparada em substrato material valorativo produzido em contraditório judicial. Em outras palavras, a dúvida, por menor que seja, milita sempre em favor do acusado, eis que a presunção de inocência é corolário de um Estado de direito democrático.

Por fim, anoto, derradeiramente, que este juízo julga fatos praticados por pessoas e não pessoas independentemente de fatos. Assim, o fato do réu ter sido condenado em outro juízo, por outro Magistrado, não é suficiente (e não pode ser) para que este Magistrado interprete e valore os fatos de modo não racional-objetivo, mas sim de forma subjetiva, o que muito se aproximaria de um direito penal de autor, o qual, por essência, é antidemocrático. A condenação por outro juízo não gera presunção de culpa nestes autos.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da presente ação penal e ABSOLVO CLEITON GONÇALVES DE LIMA da acusação de ter infringido o artigo 33, caput, da Lei n. 11.346/06.

Determino a destruição do entorpecente. oficie-se.

P.R.I.C.

Ciência ao Ministério Público.

Osasco, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA